

1500249-54.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... negou que estivesse realizando o tráfico de drogas no local. Disse que reside com a avó. Trabalha como ajudante de pedreiro. Cumpri medida na fundação casa por tráfico de drogas. Não é verdadeira a acusação, no dia eu tinha saído para almoçar, possuía trinta reais, utilizei dez para aquisição de duas parangas de maconha e vinte reais para comprar marmite. Desconheço o muro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500249-54.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000197

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045242/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 23065424 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 21/22/592 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2045242 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR CRISTIANO DE MORAIS MATHIAS

Aos 26 de setembro de 2022, às 13:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. SANDA REGINA FERREIRA DA COSTA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: VITOR CRISTIANO DE MORAIS MATHIAS - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor constituído: Dr. DANILO AVANCINI CARBONI, - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC GILBERTO KASUGA - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC MAURO TEIXEIRA NUNES - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha da Defesa: TIAGO LOPES - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha da Defesa: NATALIA MATHIAS - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas PC GILBERTO KASUGA, PC MAURO TEIXEIRA NUNES, JOSE TIAGO LOPES e NATALIA MATHIAS.

Após, o réu VITOR CRISTIANO DE MORAIS MATHIAS foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foram apresentadas alegações finais, as quais foram gravadas através do sistema de mídia digital, disponibilizadas estas no Sistema SAJ.

Pela Defesa foi dito o seguinte: "PROCESSO N° 1500249-54.2022.8.26.0599. MEMORIAIS FINAIS: VITOR CRISTIANO DE MORAIS MATHIAS. 1. DOS FATOS: Segundo consta no APFD, Policiais Civis realizavam diligências veladas pelo Bairro Bosque dos Lenheiros. Avistaram um indivíduo de camiseta preta e amarela, entregando e recebendo algo de um indivíduo, em atitude suspeita de venda de entorpecentes. Ao dar a volta no quarteirão, observaram o mesmo indivíduo que trajava camiseta amarela e preta, mexendo em um muro não rebocado, dando a impressão que retirava algo dentre os buracos dos tijolos. Solicitado apoio a uma segunda equipe, realizaram a abordagem daquele indivíduo, identificado como VITOR CRISTIANO DE MORAES MATIAS. Indagado pelos Policiais teria confessado estar realizando a mercância de entorpecentes. Em busca pessoal, localizaram em seu bolso 2 (duas) porções de erva esverdeada, aparentando ser maconha, com o peso bruto de 1,7gramas e R\$20,00 (vinte) reais em espécie. Questionado sobre haver mais drogas, prontamente esclareceu ter homiziado porções de crack nos buracos dos tijolos em um muro sem reboco, sendo ali localizadas 13 (treze) porções de pedra amareladas aparentando ser crack, com peso bruto de 3,2 gramas. Em varredura naquela via, localizaram em um cano de água mais 11 (onze) porções) de erva esverdeada, com peso bruto de 11,8 gramas, semelhantes às duas encontradas em sua posse, mas este negou serem de sua propriedade. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante ao acusado, por suposta prática do crime tipificado no art.33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Denúncia apresentada em fls. 86/89, por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Defesa preliminar apresentada em fls.146/148. Declaração de hipossuficiência anexada em fls.111. Após realizada audiência de instrução, a defesa entende que a ação penal deverá ser julgada IMPROCEDENTE. PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA. O Policial Civil, condutor e primeira testemunha, GILBERTO KASUGA, disse em juízo que, é policial civil lotado na 2.a Entorpecentes - Deic - Deinter 9 e nesta data encontrava-se em companhia do policial MAURO, com viatura descaracterizada, realizando diligências veladas pelo bairro Bosque dos Lenheiros. Avistou um indivíduo de camiseta preta e amarela, entregando e em contrapartida recebendo algo de um indivíduo, em atitudes típicas de transação de venda de entorpecentes. Ao dar a volta no quarteirão, observaram o mesmo indivíduo que trajava camiseta amarela e preta, mexendo em um muro não rebocado, dando impressão que retirava algo dentre os buracos dos tijolos. Solicitado apoio a uma segunda equipe, realizaram a abordagem daquele indivíduo, sendo ele naquele momento identificado como sendo VITOR CRISTIANO DE MORAES MATIAS, o qual prontamente confessou estar realizando a mercancia de entorpecentes. Realizada busca pessoal, localizaram em seu bolso 2 porções de maconha e R\$ 20,00 em espécie. Ao ser questionado sobre haver mais entorpecentes de sua propriedade, prontamente esclareceu ter homiziados porções de crack nos buracos dos tijolos de um muro sem reboco, sendo ali localizadas 13 porções de crack. Efetuada varredura naquela via, localizou-se em um cano de água 11 porções de maconha, as quais VITOR negou serem de sua propriedade. Deu-lhe voz de prisão em flagrante. Disse que não conhecia o réu. Disse que o réu se encontrava próximo ao muro sem reboco aonde foram encontrados as pedras de "crack", todavia, não trazia "crack" consigo, tão somente duas porções de maconha. Quanto as demais porções de maconha, este negou a propriedade. O Policial Civil e segunda testemunha, MAURO TEIXEIRA NUNES, foi no mesmo sentido, disse que nesta data estava

na companhia do policial GILBERTO, em viatura descaracterizada, em diligências veladas pelo bairro Bosque dos Lenheiros, quando avistaram um indivíduo de camiseta preta e amarela, entregando e em contrapartida recebendo algo de um indivíduo, em atitudes típicas de transação de venda de entorpecentes. Ao darem a volta no quarteirão, notaram o mesmo rapaz que trajava camiseta amarela e preta, mexendo em um muro não rebocado, dando impressão que retirava algo dentre os buracos dos tijolos. Foi solicitado apoio a uma segunda equipe e realizaram a abordagem daquele indivíduo, sendo ele naquele momento identificado como sendo VITOR CRISTIANO DE MORAES MATIAS, o qual prontamente confessou estar realizando a mercancia de entorpecentes. Em busca pessoal, encontraram em seu bolso 2 porções de maconha e R\$ 20,00 em espécie. Ao ser perguntado sobre haver mais entorpecentes de sua propriedade, prontamente esclareceu ter homiziados porções de crack nos buracos dos tijolos de um muro sem reboco, sendo ali localizadas 13 porções de crack. Feita uma varredura naquela via, localizaram em um cano de água 11 porções de maconha, as quais VITOR negou serem de sua propriedade. Foi dada voz de prisão em flagrante ao autuado. Disse que não conhecia o réu de outras abordagens. Não conseguiram abordar o transeunte. Somente após a abordagem, o encontro dos entorpecentes, é que o réu foi advertido dos seus direitos de permanecer em silêncio e não produzir contra si mesmo. A testemunha de defesa, JOSÉ TIAGO LOPES, disse em Juízo que, disse que é tio do acusado. Não presenciou o momento da abordagem. Tomei conhecimento que ele foi preso. Ele trabalhava comigo como ajudante de pedreiro. Não tive conhecimento dele com uso de drogas. Não sei dizer se ele já possui passagem na adolescência. Trabalhava das sete da manhã as cinco da tarde. Tinha uma hora de almoço, geralmente era das onze ao meio dia, ou da meio dia as treze horas. A testemunha NATÁLIA MATHIAS, disse em seu depoimento que, não presenciei a abordagem. Não estive com ele no dia da prisão, naquela época ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Tinha conhecimento de que ele usava maconha. Interrogado o acusado VITOR, disse que na data dos fatos, tinha adquirido duas porções de maconha para seu consumo, negou que estivesse realizando o tráfico de drogas no local. Disse que reside com a avó. Trabalha como ajudante de pedreiro. Cumpri medida na fundação casa por tráfico de drogas. Não é verdadeira a acusação, no dia eu tinha saído para almoçar, possuía trinta reais, utilizei dez para aquisição de duas parangas de maconha e vinte reais para comprar marmite. Desconheço o muro em questão, tinha ido apenas buscar as duas parangas. Não confirmei que o crack era meu. Apenas as duas parangas me pertenciam, que foram adquiridas com o dinheiro recebido para almoçar. Estava em seu horário de almoço. 2. PRELIMINARMENTE: 2.1. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GARTUITA: Inicialmente, requer a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme declaração de hipossuficiência anexada em fls.111, comprovando-se, que o acusado não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e do sustento de sua família. 2.2. DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL DO ACUSADO. Inicialmente, forçoso reconhecer que a suposta confissão informal do acusado, no momento da abordagem, de que estaria realizando o comércio ilícito de entorpecentes, é ilegal e não poderá ser considerada como prova válida, eis que não há qualquer prova de que foram respeitados seus direitos constitucionais quando da sua obtenção. Desta forma, temos que a versão apresentada pelos Policiais Civis, de que o réu teria assumido que estaria realizando a mercância ilegal no local dos fatos, deve ser declarado nula. Ademais, há de se notar que perante a Autoridade Policial, desacompanhado de advogado, o réu permaneceu em silêncio, desta forma, se realmente tivesse confessado o crime aos Policiais, certamente o faria novamente perante a Autoridade Policial, o que não ocorreu. Por outro lado, a suposta confissão não foi captada por qualquer vídeo ou sequer colhida de maneira formal, assim, NÃO é possível, sem sombra de dúvida, ter conhecimento se realmente ocorreu e em quais circunstâncias teria o acusado confessado a prática delitiva. Com efeito, a Constituição Federal, prevê, em seu art.5º, inciso LXIII, " o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado". Ora, se fosse possível considerar válida a confissão informal, a persecução penal seria, de pronto, transferida para o agente policial que iria escolher quem seria processado, ao arrepio das provas concretas e

palpáveis. Quanto à fragilidade aventada, segue julgado recente da Egrégia 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vejamos: Apelação. Comércio ilegal de munição. Sentença procedente. Recurso defensivo. Preliminar. Ilicitude probatória. Violação ao direito a não autoincriminação. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para o delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003. Aplicação da suspensão condicional do processo. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena no mínimo legal; b) aplicação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1. Preliminar. Confissão informal quanto à comercialização ilícita das munições. Violação ao direito ao silêncio. Qualquer pessoa tem o direito de permanecer em silêncio, de não declarar qualquer informação que resulte em auto-incriminação. Art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 8.2.g, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Norma de eficácia imediata, direito que independe de regulamentação por norma infraconstitucional. Necessidade de advertência ao direito ao silêncio em qualquer fase da persecução penal e por qualquer agente estatal. Precedentes da Suprema Corte norteamericana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos Tribunais Superiores Pátrios. Inadmissibilidade da prova ilícita. 2. Exceções à prova ilícita por derivação. Ilicitude da confissão informal do réu que não é capaz de contaminar outros elementos probatórios. Apreensão das munições decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão. Fonte independente preexistente. Desconsideração das referências feitas pelos policiais à confissão informal. Subsistência dos demais relatos não relacionados com a prova ilícita. Confissão judicial do réu que não é atingida pela prova ilícita. Desconexão causal. Réu que admitiu a posse das munições. Aplicação do art. 157, do Código de Processo Penal que se impõe. Precedentes da Suprema Corte norteamericana reconhecidos pela jurisprudência nacional e incorporados na legislação. 3. Desclassificação da conduta prevista no art. 17, da Lei nº 10.826/2003 para o art. 12, da Lei nº 10.826/2003. Elementos probatórios lícitos que permitem a configuração do delito de posse irregular de munição. Réu confesso. Decreto 9.847/2019: calibre nominal que passou a ser considerado de uso permitido. 4. Impossibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo. Ausência dos requisitos. 5. Dosimetria da pena que não merece reparo. 6. Alteração para o regime aberto que se impõe diante do quantum da pena aplicado e da primariedade do acusado. 7. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação nº 1500308-45.2020.8.26.0556- TJSP- 16ª Câmara Criminal- Rel. Des. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI, julgado em 1/06/2021, Dje em 11/06/2021). Apelação criminal Furto qualificado Sentença condenatória Preliminar de nulidade, em razão da ausência de advertência sobre o direito ao silêncio antes da confissão informal do réu Acolhimento Imposição às autoridades, policiais e judiciais, da obrigação de advertir o réu sobre seu direito de permanecer em silêncio e não se autoincriminar, sob pena de nulidade (Miranda warning) Artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e artigo 8.2.g, da Convenção Americana de Direitos Humanos Confissão informal do réu que conduziu à localização da res furtiva Teoria dos frutos da árvore envenenada Ilicitude que contaminou os principais elementos probatórios Inexistência de força compensadora de outras provas lícitamente obtidas para manter a condenação Insuficiência probatória reconhecida Absolvição como único desfecho compatível com estado do processo (artigo 386, VII, do Código de Processo Penal) Recurso provido. (Apelação nº 1500276-42.2019.8.26.0599- TJSP- 13ª Câmara Criminal- Rel. Des. LUIS GERALDO LANFREDI, julgado em 21/07/2021, Dje em 25/07/2021). Assim, na dúvida, se foi o réu cientificado pelos agentes da lei, a cerca do seu direito constitucional de permanecer calado e não produzir provas contra si, uma vez que houve violação ao direito constitucional do acusado, deve se reconhecer a imprestabilidade da suposta confissão informal, a respeito da suposta mercância ilícita, bem como das provas dela oriundas (13 porções de crack fls.2/3) de acordo com o previsto no art.5º, LXIII da Consituição Federal, Art. 6, inciso V e 186, ambos do Código de Processo Penal, aplicando-se a regra do art.157, caput, e parágrafos do Código de Processo

Penal. 3. DO MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28, DA LEI 11.343/2006. PENA DE ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS. No mérito, temos que o réu confessou a propriedade tão somente de duas porções de maconha que se destinavam ao seu consumo próprio, assim, restam ausente indícios de autoria delitiva quanto ao crime tipificado no art.33, caput, da Lei 11.343/2006. Com toda a venia a Manifestação do Ilustre Promotor de Justiça, a quantidade por si só não é apta o suficiente a ensejar uma condenação pelo crime tipificado no art.33, caput da Lei 11.343/2006, uma vez que não há nenhuma previsão no referido diploma legal a respeito da quantidade. Conforme narrado pelos próprios Policiais, o réu ao ser indagado, negou que as demais porções de maconha, embalada de maneira idênticas as que se encontravam em seu poder, fossem de sua propriedade. Também não se pode lhe atribuir as drogas tão somente por se encontrarem embaladas de forma semelhantes, uma vez que assumiu que teria acabado de adquirir os entorpecentes para seu consumo pessoal desta forma, é evidente que as drogas que foram encontradas próximo ao local em que adquiriu o entorpecente, estariam embaladas de forma semelhante. Por outro lado, os Policiais Civis, não puderam atestar, sem sombra de dúvida, que era o acusado que realizava o tráfico no local, uma vez que no momento em que visualizaram a entrega e recebimento, não souberam atestar se este teria recebido dinheiro ou as drogas para consumo, bem como, informaram perante a Autoridade Policial, que tiveram a "IMPRESSÃO DE QUE RETIRAVA ALGO DO MURO", portanto não tinham certeza. Também, podemos verificar, que no muro em questão, NÃO havia maconha, e tão somente "crack", todavia, em posse do acusado NÃO foi encontrada qualquer porção de crack, somente de maconha, evidenciando, que os Policiais Civis, se equivocaram, quando tiveram a impressão de que ele retirava algo do muro. O acusado comprovou nos autos fl. 112, que possuía atividade lícita, e tinha condições de ter adquirido o entorpecente, que possui baixo valor (2 porções de maconha). Assim, devem haver nos autos demais indícios de autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de drogas, a simples palavra da testemunha de acusação, dissasociada de demais elementos de prova, não permitem a conclusão de que a droga se destinava ao comércio ilegal, ou sequer que pertencia ao acusado. A defesa não cabe o ônus da prova e sim a acusação, e não se desimcuimbiu de seu ônus. Como se sabe, no processo criminal tudo deve ser cabalmente provado, sem nenhuma sombra de dúvida, os fatos devem ser realmente esclarecidos, em todos os seus detalhes e circunstâncias, nada pode ser presumido. Não havendo qualquer prova nos autos de que o réu estivesse comercializando entorpecentes, não pode ao final da instrução ser condenado com base apenas e-no depoimentos dos Policiais. Sequer foi realizado campanhas ou investigação prévia dando conta de que o réu estaria envolvido com o comércio ilegal de drogas, caso contrário fosse, certamente haveriam fotografias e vídeos comprovando todo o alegado pelas testemunhas de acusação. Bem como, os Policiais em seus depoimentos disseram que NÃO conheciam o réu dos meios Policiais ou abordagens anteriores. É evidente que as provas colhidas nos autos não são capazes de atestar a tipificação em relação ao tráfico de entorpecentes ao acusado. Assim a conduta do acusado se enquadra perfeitamente ao crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, a qual tipifica a seguinte conduta: Artigo 28 Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: advertência sobre efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade; medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo; Eis que tal medida é de rigor, visto que a situação do acusado é de tratamento médico e não de privação de liberdade. Dizer que a quantidade é prova suficiente da prática do comércio ilícito de entorpecente é desprezar as lições de Direito Penal e Processual. É preciso que a acusação demonstre, ainda que com base em indícios verossímeis e concatenados, e os indícios também devem ser certos e provados, que o agente visava entregar a droga ao consumo de terceiros. Quando da prova produzida não se pode chegar a esta conclusão, a decisão absolutória é a que se impõe, com relação ao crime tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006. O elemento subjetivo do tipo, o dolo, como diz a respeito à intenção do agente, não é perceptível, afim de se enquadrar na conduta tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e sim no

art. 28 do mesmo diploma legal. Na ausência de certeza quanto à autoria do delito, vigora o princípio do in dubio pro reo, pois a dúvida, resultado da insuficiência de provas, deve ser sempre interpretada em benefício do réu, devendo ser a conduta do réu DESCLASSIFICADA para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por medida de Justiça. 4. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART.33, §4º DA LEI 11.343/2006, EM SEU GRAU MÁXIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. A título de argumento subsidiário, caso Vossa Excelência entenda restar caracterizada e provada a autoria delitiva no presente caso, forçoso reconhecer estarem presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, reconhecendo o tráfico na modalidade privilegiada. Embora a capitulação jurídica dos fatos narrados na denúncia seja grave, a defesa levou ao conhecimento deste Juízo circunstâncias que atestam a boa conduta social do acusado, o qual não possui personalidade voltada ao crime, tampouco integra organização criminosa. As provas dos autos, denotam que o acusado é trabalhador, sempre manteve uma conduta social digna e honesta, é PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. Com efeito, o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 elenca como requisitos para a redução da pena os seguintes: A-) primariedade; B-) bons antecedentes; C-) não dedicação a atividades criminosas. D-) não integração de organização criminosa; No caso vertente é possível observar que o réu possui todos os requisitos para ser beneficiado com o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, possui atividade lícita, tudo a demonstrar que não se dedica-se a prática de delitos, não há nenhuma prova nos autos que induza ao reconhecimento de uma organização criminosa, tampouco que o réu a integre, DE MODO A AUTORIZAR, ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, A APLICAÇÃO

DA BENESSE EM FAVOR DO RÉU. A Sexta Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, por si só, não devem servir de supedâneo para se negar a aplicação do redutor específico previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, notadamente porque tais circunstâncias não estão previstas no aludido dispositivo legal, nesse sentido decidiu o eminente Ministro do Egrégio STJ, Dr. SEBASTIÃO ALVES DOS REIS JUNIOR, in verbis: (...) refletindo com mais vagar sobre o assunto e pedindo vênias à eminente Relatora, chego à mesma conclusão a que chegou o Ministro Teori: a quantidade e a qualidade de drogas, por si só, não podem impedir a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A lei, a meu ver, é clara nesse sentido, considerando-se que garante ao réu a redução de sua pena desde que seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Presentes essas quatro circunstâncias, não há como negar tal direito ao réu. Não há aqui recusa ao disposto no art. 42 da mesma Lei, tendo em vista que a quantidade e/ou qualidade de drogas pode ser utilizada tanto para caracterizar a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa como para dimensionar o tamanho do benefício a ser concedido. Existe assim uma sutil diferença, bem pontuada pelo Ministro Teori, entre considerar a quantidade e/ou qualidade como elemento que demonstra o fato de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e afastar o redutor apenas indicando como motivo a quantidade e qualidade de drogas, sem qualquer comprovação de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. A presença de um ou outro uso da qualidade e/ou quantidade de drogas deve ser examinada caso a caso(...) STJ-HC 343.290/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016. A Colenda Sexta Turma do Excelso STJ, atualmente, reafirmou o entendimento outrora externado no sentido de que a quantidade e natureza da droga, por si só, de forma isolada, não é apta para vedar a aplicação do redutor, in verbis: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTAIS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA INEXPRESSIVA. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NO GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS VÁLIDOS A DEMONSTRAR QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. Ausente a

impugnação específica do fundamento da decisão agravada, o agravo regimental não pode ser conhecido, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. No caso, há flagrante ilegalidade na dosimetria, uma vez que a pena-base foi majorada com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, qual seja, 17,980 gr. (dezessete gramas e novecentos e oitenta miligramas) de cocaína. No entanto, a exasperação mostrou-se desproporcional e desarrazoada, sobretudo em razão de a quantidade de droga não ser expressiva e de não ter havido valoração negativa de nenhuma outra circunstância judicial. Da mesma forma, não há fundamentação suficiente para indeferir a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não se olvida da retirada orientação desta Corte de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação às atividades criminosas. Na espécie, porém, não foram indicados elementos válidos para afastar a benesse legal, além de não se revelar significativa a quantidade de droga apreendida. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para redimensionar as reprimendas e, por consequência, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. (STJ- AgRg no AREsp 1307650/SP, rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/018, DJe 05/11/2018). HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO D ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33 § 4º, DA LEE N. 11.343/2006. NEGATIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS, MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. O Tribunal de origem não logrou fundamentar de maneira idônea a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A simples menção à quantidade e à diversidade das drogas, dissociada de qualquer outro elemento, não é suficiente para se concluir acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas ou participação em organização criminosa, afastando, peremptoriamente, a incidência da referida benesse. Fixada a pena-base no mínimo legal e, aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, sendo a reprimenda final da paciente igual ou inferior a 4 anos e 2 meses de reclusão, é possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Habeas coprus concedido a fim de reduzir a pena do paciente para 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. (STJ- HC nº 399.833/SP, MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 24/08/2017). Também não há o que se falar que a anotação de atos infracionais, durante a menoridade, é suficiente para afastar a aplicação do redutor de pena, nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIIS EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719/STF. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social. 2. A existência de ações penais em curso e de atos infracionais anteriores não constitui em princípio fundamento válido para justificar a negativa da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes. 3. Uma vez estabelecido regime mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito, em contrariedade às Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, faz jus ao regime aberto e à substituição das penas. 4. Agravo regimental improvido"(Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.906.504 – SP, Relatoria do Ministro Olindo Menezes). "[...] A impetrante ressaltou que o afastamento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pelas instâncias antecedentes deu se pelo fato de o paciente ter duas ocorrências envolvendo tráfico de drogas quando menor de idade e condenação criminal sem trânsito em julgado pelo delito previsto no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Somente outras condenações transitadas em julgado poderiam afastar o benefício, o que não ocorreu na situação descrita nos autos. A prática de atos infracionais não

é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas (arts. 1º e 112) e visam à proteção integral do adolescente infrator. Os atos infracionais eventualmente cometidos e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, quando mencionados pelos magistrados, devem ser valorados com os elementos concretos constantes dos autos. A concessão daquele benefício, portanto, deve ser reapreciada pelo Superior Tribunal de Justiça por conflitar com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.054, Relator o Ministro Marco Aurélio (DJe 26.2.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a tese de que “a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como Maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”. 12. No julgamento do Habeas Corpus n. 151.431 (DJe 8.5.2018, Segunda Turma), o Ministro Gilmar Mendes, Relator, sustentou que inquéritos e ações penais em curso não podem servir de fundamentos para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Os Ministros Dias Toffi e Edson Fachin divergiram do Relator, mas, pelo empate, a ordem foi concedida, nos termos da seguinte ementa: “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como Maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como Maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares

ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria” (HC n. 151.431, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.5.2018)”. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 193816 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-010 DIVULG 20-01-2021 PUBLIC 21-01-2021). Assim, em caso de condenação do acusado nos termos da denúncia, ressalvado o entendimento de Vossa Excelência, entendemos que é o caso de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CONFORME ART. 33, § 2º, B, DO CÓDIGO PENAL. Caso reste afastada a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o que admitimos apne as de forma hipotética, necessário se faz determinar o regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado. Conforme artigo 33 do Código penal, § 2º, b, in verbis: Art. 33 A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência em regime fechado. (...) § 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. (...) b) O CONDENADO NÃO REINCENTE, CUJA PENA SEJA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDA A 8(OITO) ANOS, PODERÁ, DESDE O PRINCÍPIO, CUMPRIR- LA EM REGIME SEMIABERTO. Logo, sendo o recorrente primário, tendo sido a pena base fixada no mínimo legal, caberá a aplicação de regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena corporal. O Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas

Corpus n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º §1º, da Lei n. 8072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma a obrigatoriedade de imposição de regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade de reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância apreendida (art. 42da Lei nº 11.343/2006). Considerando o quantum da condenação pelo crime de tráfico de drogas e a primariedade do réu, o regime cabível na espécie é o semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, §§2º, "b", e 3º, do Código Penal, e nos termos dos enunciados das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE OITO ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. PACIENTE PRIMÁRIO, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. No caso, as instâncias de origem estabeleceram o regime prisional fechado levando em conta apenas a gravidade em abstrato da conduta perpetrada, circunstância que não autoriza a conclusão de que o comportamento do agravado reveste-se de maior grau de reprovabilidade. 3. Considerando o quantum da condenação (8 anos), a primariedade do agravado e o fato de não lhe terem sido apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime cabível na espécie seria o semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal. 4. Regime intermediário cabível, nos termos dos enunciados das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, bem como do enunciado da Súmula n. 440 desta Casa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 563.004/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) – grifo nosso. Nesses termos, requer seja determinado o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º alínea "b" do Código Penal, bem como nos termos dos Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, e 440 deste Superior Tribunal de Cidadania. 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA R. SENTENÇA. Por fim, a defesa entende que não estão mais presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, uma vez que incerrada a instrução tendo colaborado o réu, demonstrando arrependimento pela prática delituosa, requer a Vossa Excelência CONCEDA ao recorrente o direito de recorrer em liberdade da r. Sentença".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:
"Vistos.

VITOR CRISTIANO DE MORAIS MATHIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta da denúncia que, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 12 horas e 15 minutos, na Rua Castanheira nº 308, Bairro Mário Dedini, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiro, 2 invólucros de plástico contendo fragmentos vegetais (com THC), com peso bruto aproximado de 2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, na mesma ocasião, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, 13 invólucros contendo cocaína, na forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 3,1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias, o réu tinha em depósito, para fins

de tráfico, 11 invólucros contendo fragmentos vegetais (com THC), com peso bruto aproximado de 11,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o réu se postou no lugar indicado para realizar o tráfico. Policiais Civis da DEIC, que ocupavam uma viatura descaracterizada, suspeitaram do comportamento de VITOR, quando o viram entregando um objeto a desconhecido e dele recebendo algo em troca (atividade típica de tráfico de drogas). Os policiais também observaram o réu se abastecendo de drogas junto a um muro. Os servidores públicos realizaram a intervenção e a abordagem e apreenderam em poder de VITOR duas porções de maconha e a quantia de R\$ 20,00, provenientes do comércio ilícito. Ao ser entrevistado, VITOR admitiu o tráfico e apontou aos policiais o local, no citado muro, onde escondia as demais porções, sendo localizadas outras 13 pedras de "crack". Na sequência, os policiais localizaram em um cano, próximo ao local da abordagem, mais 11 porções de maconha, que estavam embaladas de forma idêntica àquelas apreendidas em poder do réu e que a ele também pertenciam.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 141) e apresentou defesa preliminar (fls. 146/148), seguindo-se a decisão de fls. 149/151, que recebeu a denúncia em 16.05.2022.

Designada audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, interrogando-se, após, o acusado.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. Sustenta a Defesa, em sede de preliminar, que seria nula a confissão informal do acusado, porquanto o réu não teria sido cientificado, quando de sua abordagem, do direito de permanecer em silêncio.

Não ficou absolutamente claro se o réu foi ou não advertido do direito ao silêncio pelos policiais responsáveis pela prisão.

O policial Gilberto nada mencionou a respeito da questão e não foi perguntado sobre o fato. Já o policial Mauro, questionado pelo defensor, afirmou, numa primeira oportunidade, que sempre orientam as pessoas abordadas. Posteriormente, perguntado sobre o momento em que foi dada voz de prisão ao réu, o policial afirmou que só o fizeram depois de localizarem a droga no local apontado pelo réu. Na sequência, o defensor afirmou "e após o encontro foi dado também para ele ciência dos direitos dele de permanecer silêncio e não produzir prova sobre si mesmo, é isso?", ao que o policial respondeu "correto".

Ainda que se pudesse reputar que houve ilicitude na conduta dos agentes públicos, que teriam questionado o réu sobre os fatos antes de adverti-lo do direito ao silêncio, a apreensão do entorpecente não decorreu exclusivamente da informação prestada pelo acusado e não pode ser reputada prova ilícita por derivação.

Com efeito, a prova ilícita que conduz à descoberta de outra prova não terá aptidão de contaminá-la caso fique demonstrado que esta prova seria fatalmente obtida.

É o caso dos autos.

Como se observará pela fundamentação abaixo, os policiais flagraram o réu acessando um ponto de um muro e vieram a encontrar entorpecentes exatamente nesse local, bem como em um cano, próximo ao muro, que foi por eles vistoriado.

Logo, a localização da droga resultada de fonte independente e teria ocorrido ainda que o réu não tivesse indicado informalmente a localização do entorpecente.

Nesse contexto, afasto a preliminar arguida.

2. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal da ré.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pela fotografia de fls. 23 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 76/78, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Quando da lavratura do ato de prisão em flagrante, o réu fez uso de seu direito de permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, negou a prática do crime. Disse que tinha saído em seu horário de almoço e foi ao local onde pegou duas "parangas" de maconha. Afirmou que pagou R\$ 10,00

pela droga e ficou com R\$ 20,00. Asseverou que a pessoa que lhe vendeu a droga não foi abordada. Declarou que, em momento algum confessou a prática do tráfico e a propriedade das drogas encontradas, posto que só as duas porções de maconha encontradas em seu poder lhe pertenciam e eram para seu uso.

A prova produzida, porém, é maciça e incriminadora.

O policial civil Gilberto relatou que estavam em diligência com viatura descaracterizada pelo bairro Bosque dos Lenheiros, em local já conhecido como ponto de tráfico, quando visualizaram o réu fazendo contato com um transeunte, recebendo e entregando algo. Em razão disso, suspeitaram tratar-se de tráfico de entorpecentes. Então, deram a volta no quarteirão e, quando retornaram, o réu estava mexendo num muro baixo sem reboco e foi abordado. Atestou que, com o réu, encontraram duas porções de maconha e R\$ 20,00, tendo ele confessado que passava necessidades e estava traficando. Asseverou que ele falou que estava ocultado porções de "crack" no muro que ele acessou, onde apreenderam 13 porções de "crack" e, num cano de água, acharam 11 porções de maconha, iguais as que estavam com ele, mas ele falou que não eram dele, que ele só comercializava o crack. Aduziu que o réu afirmou que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Mauro.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Logo, sequer é razoável supor que os policiais imputassem a posse de entorpecente e a prática de tráfico a pessoa que sequer conheciam.

De outro lado, as testemunhas José e Natália nada esclareceram sobre os fatos, limitando-se a prestar informações sobre os antecedentes e conduta social do acusado.

Enfim, o fato de os policiais terem flagrado apreendido porções de entorpecentes em poder do réu e também no muro que ele acessou e no cano de água perto do muro, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova, conduz à certeza quanto à autoria.

A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e à flagrância de atos típicos de tráfico, deixam evidente que a droga se destinava mesmo ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. -

Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não

comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

3. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal. (autos 0017317-94.2015 da Vara da Infância e da Juventude, cf. certidão de fls. 96/102).

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena-base no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.

Inexistem causas de aumento. De outro lado, o réu não tem antecedentes criminais e não há indícios de seu envolvimento com o crime organizado. Assim, reduzo a pena fixada em dois terços, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, totalizando um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa. Consigno que, embora haja notícia nos autos de que o réu teve passagem por ato infracional enquanto adolescente (autos 0017317-94.2015 da Vara da Infância e da Juventude, cf. certidão de fls. 96/102), o fato ocorreu em 2015, ou seja, há pelo menos sete anos, não podendo, pois, obstar o reconhecimento do privilégio, porquanto não indica que o réu se dedicava a atividades criminosas.

Quanto à substituição da pena corporal por restritiva de direito, muito embora, em tese, possível, comungo do entendimento de que a benesse é incompatível ao condenado por crime de tráfico, não em função de impeditivo legal, mas pela periculosidade social presumida, incompatibilizando o autor de delito dessa natureza com atividades comunitárias ou assistenciais, na medida em que o recoloca em contato direto com grupo suscetível ao seu assédio (cf. Apelação nº 0004555-80.2014.8.26.0451, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 26.01.17).

Observo que o art. 44 do Código Penal, em seu inciso III, expõe elementos a serem considerados quando da substituição da pena corporal por restritiva de direito, consignando, ao final, a necessidade de que a substituição seja